

1500331-84.2021.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... João Vitor. Nunca ouviu que ele praticasse tráfico de drogas.

Jeferson Donizete da Silva disse que conhece João Vitor e avistou viaturas policiais pelas imediações, mas não viu o acusado correr. Nunca ouviu sobre envolvimento de João Vitor com tráfico de drogas. Sabe que o local conhecido como "casinha" é frequentado por usuários.

Tabata Keila Pereira Carvalho disse que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500331-84.2021.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500331-84.2021.8.26.0546

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR DO COUTO BUENO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

João Vitor do Couto Bueno, menor de 21 anos e Wendel Aparecido Crimones foram denunciados e estão sendo processados, porque no dia 10 de setembro de 2021, por volta das 17h40min, na Rua Osvaldo Carvalho nº 204, bairro Jardim Itamaracá, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações de sedes de entidades beneficentes e de recinto onde se realizam diversões de qualquer natureza, traziam consigo, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico e entrega a terceiros, 47 (quarenta e sete) microtubos contendo cocaína, com peso bruto de aproximadamente 28g (vinte e oito gramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, e o faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Por defensores constituídos, os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 131/152 e 195/196) e a denúncia foi recebida aos 02 de fevereiro de 2002 (fls. 197/198).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e os réus foram interrogados.

Em memoriais, a representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, condenando os acusados nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer a improcedência da ação penal, com consequente absolvição dos réus,

sustentando que a prova produzida é insuficiente e o relato dos policiais revelou-se contraditório. Em caso de condenação, os defensores requerem benesses quanto à pena aplicável..

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 08), pelo laudo pericial do local (fls. 109/113); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 104/108) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O policial militar Leandro Henrique Cândido disse que estava em patrulhamento pelo bairro, quando o policial militar Wesley informou que pessoas haviam se evadido da equipe dele. Deparou-se com João Vitor, que estava correndo e olhando para trás. Efetuiu a abordagem e nada ilícito foi apreendido com ele. Entrou novamente em contato com o cabo Moreira e ele confirmou que se tratava do indivíduo que havia se evadido da equipe dele. Disse que a equipe do cabo Moreira apreendeu aproximadamente 40 porções de droga. Ainda, o policial Kleber informou ao depoente que havia abordado o segundo indivíduo. Disse que o acusado Wendel foi abordado em local próximo à avenida Mogi Mirim.

O policial militar Wesley Luís da Silva Moreira disse que estava em patrulhamento pelo bairro Itacolomi, quando foi abordado por um indivíduo, que disse que dois agentes, de nome João e Wendel, estariam praticando tráfico de drogas e que a droga estaria escondida atrás da empresa Polo. Iniciou o patrulhamento e avistou os dois indivíduos abaixados e pegando algo. Quando notaram as motocicletas, eles se evadiram, pulando cercas e barranco. O depoente comunicou o fato às equipes do Sargento Leandro e soldado Kleber, que conseguiram abordar os acusados. No local onde os acusados estavam agachados, apreendeu 47 pinos de cocaína. Os acusados disseram que estavam no local para adquirir droga, pois são usuários. Avistou os dois acusados agachados e dispensando as drogas. Acredita que Wendel tenha sido abordado a 600 ou 800 metros de distância do local onde visto inicialmente. Não sabe quanto tempo depois Wendel foi conduzido de volta ao local onde inicialmente visto pelo depoente.

O policial militar Douglas Vilela Maganha prestou depoimento no mesmo sentido do policial Wesley Moreira, confirmando o recebimento de denúncia feita por popular de que os acusados guardavam drogas em empresa desativada na Rua Osvaldo de Carvalho. Deslocou-se e visualizou os acusados agachados e eles, ao avistarem a equipe policial, evadiram-se e dispensaram invólucros de cocaína, que foram arrecadados e totalizaram 47 porções. Confirma que viu ambos os acusados dispensando as porções durante a fuga. Disse que Wendel foi conduzido à presença do depoente aproximadamente dez minutos depois.

Kleber Aparecido Appolinário de Souza disse que estava em patrulhamento pelas imediações quando foi acionado pelo cabo Moreira, que lhe disse que Wendel havia se evadido após dispensar drogas. Durante o patrulhamento, avistou Wendel, que já estava cansado, e disse que estava no local onde foi visto pelo policial Moreira para usar droga.

Nilza de Fátima Garbim dos Santos disse que voltava da academia e avistou João Vitor no interior de uma viatura. Avisou a genitora de João Vitor. Nunca ouviu que ele praticasse tráfico de drogas.

Jeferson Donizete da Silva disse que conhece João Vitor e avistou viaturas policiais pelas imediações, mas não viu o acusado correr. Nunca ouviu sobre envolvimento de João Vitor com tráfico de drogas. Sabe que o local conhecido como "casinha" é frequentado por usuários.

Tabata Keila Pereira Carvalho disse que conhece o acusado Wendel da "casinha", que é local frequentado por usuários de drogas e bebida alcoólica. Nunca ouviu sobre envolvimento de Wendel com tráfico de drogas. Disse que a linha férrea fica distante de sua residência, aproximadamente 40 minutos de caminhada.

Ducineide Gouveia da Silva disse que reside em frente à linha férrea, no bairro Itamarati. Disse que sua casa fica a 25 minutos de distância da avenida Mogi Mirim. Na data do fato, viu o acusado ser abordado por policiais. Tem conhecimento de que Wendel é usuário de droga.

Em solo policial, os acusados permaneceram calados (fls. 09 e 10).

Em juízo, o acusado Wendel disse que a acusação não é verdadeira. Estava voltando a sua casa quando foi abordado pelos policiais militares e estava na posse de cinco invólucros de cocaína, para seu consumo pessoal. Nega que tenha comparecido às dependências da empresa desativada. Não conhece o corréu. Disse que é conhecido dos policiais militares em razão de seus antecedentes.

Em juízo, o acusado João Vitor disse que não estava em companhia do corréu na data do fato e nega que tenha comparecido às dependências da empresa desativada. Informa que havia consumido drogas na ocasião. Não conhece o corréu e já havia sido abordado pelos policiais militares ouvidos nesta data.

Com efeito, o depoimento prestado pelos policiais militares é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que os acusados realmente se dedicavam ao tráfico em razão da quantidade e forma como a droga apreendida estava embalada, vale dizer, invólucros fracionados, características típicas do tráfico varejista.

Deve-se pontuar que os policiais militares Wesley Moreira e Douglas Maganha foram seguros e afirmaram de maneira harmônica que avistaram os acusados na área de empresa desativada, onde ambos estavam agachados e se evadiram quando notaram a presença da equipe policial.

Ainda, apesar da negativa dos acusados, os policiais militares Wesley e Douglas disseram que já conheciam os acusados e, por isso, identificaram que ambos estavam na área da empresa desativada e correram quando perceberam que seriam abordados, o que condiz com o relato apresentado pelos policiais Kleber e Leandro, que detiveram, respectivamente, Wendel e João Vitor e disseram que ambos estavam correndo quando foram vistos.

Aliás, o policial Kleber disse que Wendel estava esgotado, o que corrobora que tenha se evadido e sido abordado a considerável distância do ponto onde inicialmente visto pelos policiais Wesley e Douglas.

Nesse caso, apesar da negativa dos acusados, a prova oral produzida demonstra com segurança que os increpados foram vistos dispensando as 47 porções de cocaína, que foram arrecadadas em seguida.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que os acusados traziam e guardavam quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, devem ser dados como incursos naquele preceito legal. A esse respeito:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663). “Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos policiais militares, na medida em que todos eles disseram que já haviam abordado os acusados e nada ilícito

apreendido com eles nas ocasiões anteriores, de modo que não se vislumbra nenhum indício para imputarem falsamente o crime aos acusados justamente na presente oportunidade.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, fixo a pena privativa de liberdade em seu patamar mínimo, por entender que a quantidade apreendida não destoa significativamente do que normalmente se vê em casos semelhantes, especialmente porque a quantidade indicada no laudo pericial de exame toxicológico não é expressiva a justificar o recrudesimento (fls. 107).

Nesse cenário, fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, para ambos os acusados.

Em segunda fase, o acusado Wendel é reincidente, por força da condenação nos autos n. 000110-20.2017 (fls. 237) e nos autos n. 0007693-55 (fls. 237/238).

Desse modo, aumento sua pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e o pagamento de 583 dias-multa.

Em relação ao acusado João, anoto a atenuante da menoridade relativa, mas, tendo sido fixada a pena no mínimo legal, não poderá ficar aquém daquele patamar (súmula 231 do STJ).

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial de local revela que nas imediações do local onde os fatos ocorreram existem entidades beneficentes, como a Pastoral da Criança e a Casa de Apoio Familiar Associação Agape (fls. 111/116), o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas devido ao maior fluxo de pessoas.

Aliás, a lei não exige que aqueles sejam os locais especialmente visados pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas “Zumira” e “Rubens Leme Asprino” (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal) Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que “(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias.” (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes fundamentos, majoro a pena de cada um dos acusados em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, para o acusado Wendel, e pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, para o acusado João Vitor.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no

art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em benefício do acusado Wendel, por força de sua múltipla reincidência.

Por outro lado, entendo possível a incidência do benefício em favor do acusado João Vitor, com redução da pena em 2/3, resultando pena privativa de liberdade de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa.

Embora ostente anotação perante o juízo da infância e juventude local, os documentos de fls. 246/251 revelam que a representação ofertada lhe imputa a conduta de trazer consigo 4 porções de cocaína e uma de maconha, sem que tenha sido prolatada sentença, reconhecendo, ou não, a prática infracional pelo increpado. Essa é a conclusão que decorre do documento de fls. 251, de modo que temerário vedar a incidência do redutor sem tenha sido confirmada a prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas.

Essa é a conclusão que decorre do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

6. Os atos infracionais só podem ser utilizados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa para fins de afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, que deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção). 7. A presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas quando o afastamento do tráfico privilegiado fundou-se na simples existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação criminal definitiva, no registro de atos infracionais e na quantidade de droga apreendida não se harmoniza com a orientação predominante do STF (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 613.508 - SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, julgado aos 15/3/2022) Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade imposta ao acusado Wendel deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, pois duplamente reincidente, sendo ainda inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta e por força da reincidência.

A pena privativa de liberdade imposta ao acusado João Vitor deverá ser cumprida em regime inicialmente aberto, pois esse é mais recente entendimento da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu Habeas Corpus coletivo para proibir que os juízes e desembargadores da Justiça de São Paulo apliquem regime fechado a presos enquadrados no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), estendendo, inclusive, aos condenados que já cumprem pena nessa situação, casos onde deverão ser efetuadas as devidas correções, conforme a seguinte ementa:

"PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1)."

O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que o réu João Vitor faz jus à aplicação do artigo 44 do Código Penal.

Substituo, portanto, a pena privativa de liberdade imposta pela prática do crime por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas pelo mesmo período da privativa de liberdade, de forma e molde a ser deliberados em sede de execução, e pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a entidade pública ou privada, com destinação social.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO Wendel Aparecido Crimones à pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias, em regime inicial

fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, e CONDENO João Vitor do Couto Bueno à pena privativa de liberdade de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 194 dias-multa, cada qual no mínimo legal, por incurso no art. 33, §4º, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma da fundamentação em relação a este último.

O réu Wendel respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, especialmente porque se trata de agente duplamente reincidente, o que reforça a necessidade de acautelar a ordem pública. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado Wendel não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

O acusado João Vitor poderá recorrer em liberdade.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 31 de março de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA